

0000655-05.2017.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WENDELL DE OLIVEIRA GALLUZZO e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

KAUAN DE SOUZA WEBBER e WENDELL DE OLIVEIRA GALUZZO, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do artigo 33, caput, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0000655-05.2017.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000655-05.2017.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WENDELL DE OLIVEIRA GALLUZZO e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

KAUAN DE SOUZA WEBBER e WENDELL DE OLIVEIRA GALUZZO, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 22 de março de 2017, por volta das 17h30min, na Rua Cuiabá, 13, Rochdale, nesta cidade e Comarca de Osasco, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, traziam consigo drogas, para entrega ao consumo de

terceiros, consistentes em 21 (vinte e um) invólucros plásticos contendo maconha, com peso líquido de 45,37g, 59 (cinquenta e nove) microtubos do tipo eppendorf, contendo cocaína, com peso líquido de 26,49g e 37 (trinta e sete) invólucros plásticos contendo haxixe, com peso líquido total de 13,22g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, laudo de constatação de fls. 17/19 e exame químico-toxicológico (fls. 176/177).

Denúncia recebida em 24 de abril de 2017 (fls. 121).

Réus citados (fls. 133 e 134). Respostas apresentadas (fls. 140/150).

Antecedentes juntados, bem como laudo químico-toxicológico (fls. 176/177).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e duas pela defesa do acusado Kauan. Ao final, os réus foram interrogados.

Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia (fls. 337/340).

A defesa de Kauan fez digressões sobre o conjunto probatório, alegou contradições e requereu a improcedência da ação penal. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da atenuante menoridade e aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, fixação de regime aberto para inicial cumprimento de reprimenda, detração substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade (fls. 344/354).

Em favor de Wendell, a defesa requereu a absolvição do acusado alegando insuficiência probatória. De forma subsidiária, pugnou desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime diverso do fechado para inicial cumprimento de reprimenda (fls. 358/380).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade ficou evidenciada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 176/177).

Quanto à autoria, a prova acusatória confirma parcialmente a imputação.

O policial Eduardo disse que estava em patrulhamento de rotina quando adentraram em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Avistaram os dois, um deles com a sacola na mão, que largou e tentou se evadir, realizando a travessia de uma "ponte de pedestre". Foram abordados. Com Kauan encontraram haxixe e quarenta reais dentro do bolso da bermuda. Afirmou que Wendell largou a sacola com mais entorpecentes. Confessaram informalmente a traficância.

Edinei disse que leu o boletim de ocorrência por não se recordar da ocorrência em razão do decurso do tempo. Disse que viu a dispensa da sacola com drogas, mas não conseguiu apontar quem a teria dispensado.

A defesa do acusado Kauan trouxe duas testemunhas que confirmaram boa conduta social do acusado.

Os réus foram interrogados, Wendell permaneceu em silêncio, Kauan disse que foi ao local comprar haxixe.

Em relação ao acusado Wendell, entendo que os depoimentos dos policiais são firmes e isentos de contradições. Ambos confirmaram que viram a dispensa da sacola que continha os entorpecentes e Eduardo afirmou que teria sido Wendell quem dispensou o entorpecente e tentou se evadir ao visualizar a viatura. Outrossim, a defesa não produziu provas próprias. Não trouxe qualquer elemento de prova que mitigasse aquelas produzidas pela acusação.

Ausentes, portanto, dúvidas com relação ao crime e à autoria. Embora enxuto, o conjunto probatório é firme e reclama a condenação.

Assim não ocorre com relação ao réu Kauan.

Entendo que a prova acusatória é insuficiente para a pretendida condenação.

Ressalto que os policiais não presenciaram o réu em atos de mercancia ilícita ou mesmo conversando com o corréu ou ainda entregando entorpecentes a usuários. Foi detido com uma pequena quantia em dinheiro e pequena porção de entorpecente, situação que condiz com a versão apresentada. Em nenhum momento confessou a traficância e alegou que estava no local para comprar as drogas. Não comprovado, portanto, o liame entre os acusados.

Por fim, a defesa trouxe testemunhas que vieram aos autos para comprovação de boa conduta social.

Relembra a jurisprudência que:

“Para que se reconheça a existência de tráfico ou comércio de drogas, é mister prova absolutamente segura. No caso de dúvida em se saber se o réu é traficante ou usuário, deve subsistir a segunda hipótese, como solução benéfica do in dubio pro reo” (TJSP – AC 133.383-3 – Rel. Egydio de Carvalho – JTJ 140/276).

“Sem embargo da grande quantidade da erva apreendida, havendo peculiaridades que tornam plausíveis as afirmações dos réus de que não pretendiam passar adiante a droga, manda a prudência sejam eles responsabilizados como usuários e não como traficantes. A prova do tráfico há de ser complementada pela acusação; não bastando para sua afirmação a única circunstância de ser grande a quantidade da substância apreendida” (TACRIM-SP – AC – Rel. Tomaz Rodrigues – JUTACRIM 58/339 - grifamos).

Recorro, também, às lições de Guilherme de Souza Nucci:

“Se a prática de uma infração penal é, sem dúvida, um mal à sociedade, mal maior é a busca de um culpado, sem qualquer cuidado e infringindo direitos fundamentais do homem. O Estado não pode ser tão mesquinho e delinquente quanto o indivíduo possa ser, de modo que condenações injustas geram mais insegurança do que o próprio cometimento do crime. O direito à prova surge vigoroso nesse quadro, porquanto é inerente à defesa, indispensável esteio do Estado de Direito. Logo, cabe a cada magistrado cuidadosamente verificar como está formando sua convicção para que sua imparcialidade, como homem e como representante do Estado, seja o mais próxima possível do ideal”.

Assim, de rigor a condenação do acusado Wendell e a absolvição de Kauan, em face da insuficiência probatória.

Passo à fixação da pena:

O réu Wendell é tecnicamente primário. Com lastro no art. 59 do Código Penal, fixo

a pena-base no mínimo legal.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Nos termos do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 e considerando a primariedade, diminuo em 2/3 (dois terços) a sanção penal.

A minguia de causas gerais ou especiais de aumento e diminuição, torno como pena definitiva 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando as poucas informações sobre as condições econômicas do acusado, mantenho o valor do dia-multa no mínimo legal.

Para o cumprimento da pena de prisão determino regime inicial aberto, em face do montante da sanção e do tempo de prisão provisória cumprido, bem como primariedade.

Neste diapasão, entendo que a exigência legislativa de regime inicial fechado e o impedimento à substituição da pena privativa liberdade, mesmo para os acusados primários e agraciados com o redutor do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, não atendem o princípio constitucional da individualização da pena,

De se lembrar o mandamento constitucional "a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito" individual (art.5º, XXXV), por completo ignorado ao se arrancar do Poder Judiciário a análise sobre a adequação de regimes e sanções. É manifesta a interferência do Legislativo sobre o Judiciário, anulando a independência e harmonia dos Poderes da República (arts. 2º e 60, §4º, inc.III/CF), com total esquecimento do preceito dignidade da pessoa humana, eleito como valor supremo da democracia.

É chegada a hora do Poder Judiciário assumir o seu verdadeiro papel, não de mero intérprete da 'vontade' - às vezes equivocada - do legislador, mas também de construtor do direito.

O excesso positivista - lei sempre como diretriz justa, a ser imperiosamente seguida, não obstante com ela se produzam iniquidades, incorreções, injustiças, representa posicionamento jurídico ultrapassado.

Estamos com Bastos, que reclama a necessidade de nos afastarmos do dogmatismo, sobremaneira na esfera penal e encararmos o direito em sua própria "realidade histórico-sociológica; exige-se, hoje, do aplicador do direito a conscientização de que a construção do direito parte dele e não exclusivamente do legislador, que nem sempre faz uma leitura correta da premissa fática que lhe é apresentada, formulando leis que, não raro, refletem somente os anseios de uma determinada classe dominante - a qual pertence este mesmo legislador - ou que, por imprecisão e ambigüidade, facilmente se adaptam às concepções pessoais do exegeta. E, se conservam alguma clareza, nada impede que se doutrine ou que se decida contra elas. Daí o caráter da lei como projeto e, não como realidade jurídica, pois o direito se concretiza à custa do suporte fático de outras matrizes, mais ou menos interligadas."

Em suma, no exercício do controle difuso, declaro inconstitucional o parágrafo quarto do art. 33 da Lei 11.343/06, no que se refere à proibição de substituição da pena privativa de liberdade.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar WENDELL DE OLIVEIRA GALUZZO, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento de 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO AO DIA, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput da Lei 11.343/06.

O Supremo Tribunal Federal já apontou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 8072/90 que anulavam o princípio da individualização penal. Por decorrência, a análise da possibilidade de substituição da sanção privativa de liberdade pela restritiva de direitos se impõe.

Em muitos julgados é corrente a aplicação das penas restritivas de direito ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando a sanção fixada na sentença não ultrapassar os quatro anos que o Código Penal estipula como requisito temporal. É a posição mais técnica e que melhor atende o princípio constitucional da individualização da pena.

Com fundamento no art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, fixada em um salário mínimo, que será revertido à entidade beneficente Seara de Jesus, com a possibilidade de parcelamento conforme as condições financeiras do sentenciado e PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS à comunidade ou entidades públicas, consoante os ditames do art. 46, §3º do Código Penal e atribuição de tarefas ao condenado conforme sua aptidão, cumpridas à razão de uma hora de serviço por dois dias de condenação (em razão da menoridade), fixada de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, em local designado pelo Juízo da Execução, com detração penal do tempo de prisão provisória já cumprido.

Transitada em julgado, o nome do condenado deverá ser lançado no rol dos culpados.

Considerando a primariedade, o montante da pena, as substituições e o regime fixado, poderá o sentenciado recorrer em liberdade.

Expeça-se o necessário.

Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER KAUAN DE SOUZA WEBBER, qualificado nos autos, da acusação do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Determino a devolução do valor apreendido com o réu Kauan, após o trânsito em julgado, se confirmada a presente.

P. R. I. C.

Osasco, 11 de agosto de 2022